

1501668-54.2021.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTINA ESCHER

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... que o réu estava inserido na dinâmica do tráfico de drogas, sendo suficiente para a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo incompatível com o alegado uso pessoal.

Nesse sentido:

"Tóxico - Tráfico - Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado - Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio

- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

2ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501668-54.2021.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501668-54.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2191758/2021 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 19067229 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 39/21/219 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 2191758 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSUE APARECIDO DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

JESSUÉ APARECIDO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 15 de julho de 2021, por volta das 14h30min., na Estrada Botucatu - Monte Alegre, Guarantã, Jardim América, nesta Cidade e Comarca, transportava, guardava e tinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiras pessoas, 34 porções de cocaína, pesando 11,10g e 304 porções de cocaína em forma de "crack", com peso líquido 168,23g, drogas estas que

determinam dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O rito da Lei 11.343/06 foi convertido em ordinário, a denúncia foi recebida (fl. 132/133), o réu foi citado (fls. 152) e apresentou defesa preliminar (fls. 147/150). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 154/155) e designada audiência de instrução. Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado. Nos memoriais escritos, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (fls. 205/210).

A defesa do réu requereu a absolvição. Caso contrário requereu a desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal. Em caso de condenação, requereu a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, da atenuante da confissão, fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade (fls. 213/219).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade do interrogatório policial, ante a alegação da ausência da assistência de advogado. Isso porque, o inquérito policial é inquisitorial de modo que a presença de defesa técnica é facultativa.

Insta trazer à baila os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

Com a edição da Lei 10.792/2003, os arts. 185 a 196 sofreram algumas alterações, embora muitas dessas modificações sejam aplicáveis somente ao processo e não à fase do inquérito. Exemplos: não é obrigatória a presença de defensor no interrogatório feito na polícia (art. 185, CPP), nem tampouco há o direito de interferência, a fim de obter esclarecimentos (art. 188, CPP), pois tais disposições dizem respeito à ampla defesa, que não vigora na fase inquisitiva do inquérito." (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal: 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019).

No mérito, a pretensão punitiva é procedente

A materialidade do delito de tráfico ficou comprovada pela juntada do auto de prisão em flagrante (fls. 01), do boletim de ocorrência (fls. 02/04), do auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, do laudo de constatação provisória de fls. 29/33, do laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 89/91, do comprovante do dinheiro depositado em juízo (fls. 80), do laudo pericial dos microtubos (ependorfs) e dos sacos plásticos (fls. 81/84), do laudo pericial balança de precisão (fls. 85/88) e pela prova oral colhida.

A autoria em relação ao tráfico de drogas está, igualmente, caracterizada.

A testemunha arrolada pela acusação Alexandre Bazzo da Cunha, Policial Civil, contou que recebeu denúncia na DISE dando conta que o réu transportava droga até a cidade de Pratânia em seu veículo, VW/Parati. Para tanto, utilizava uma estrada de terra que passava pelo bairro Monte Alegre, em Botucatu. No dia dos fatos, realizou operação. Por volta das 14h30min., a Parati passou pelo local e efetuou a abordagem. Estava o réu, a esposa e uma criança no veículo. Em busca no automóvel foram encontrados 230 papéletes de crack e cerca de 30 pinos de cocaína. Indagado informalmente, admitiu que estava traficando. Em diligências na casa do réu, encontrou uma pedra bruta de crack com 100g, 73 papéletes de crack, balança de precisão e R\$1800,00. Admitiu que estava traficando, que a droga era sua e a levava para Pratânia. O réu disse que tinha uma biqueira em Pratânia e levava droga de Botucatu para lá. A denúncia anônima, que era recente, apontava o nome do réu, local de residência e veículo (Parati bege). Admitiu que o dinheiro era produto do tráfico. Não o conhecia dos meios policiais.

A testemunha arrolada pela acusação Nilton Luiz Bassetto, Policial Civil, ratificou a versão de seu colega de profissão, acrescentando que a denúncia anônima dava conta que o réu levava drogas para Pratânia quase que diariamente. A droga encontrada no carro estava debaixo do banco do passageiro. Já tinha recebido denúncia anterior em desfavor do réu. Não o conhecia dos meios policiais.

A testemunha arrolada pela defesa José Carvalho, afirmou que o réu foi seu empregado e nada conhece que desabone sua conduta. Era bom funcionário.

O acusado, em sede policial, confessou os fatos. Admitiu que realmente a droga

localizada no interior de seu carro, na tarde de hoje, era sua. Também era sua a droga localizada em sua casa. Sua esposa não sabia da existência da droga. Ele vendia o entorpecente costumeiramente, na cidade de Pratânia, mas não quis identificar outros comparsas, quer em Pratânia ou em Botucatu. Toda a droga ora lhe exibida, realmente estavam em seu poder e tinham a finalidade de tráfico. O dinheiro, cerca de 1800 reais, eram da venda de droga. Já esteve preso no passado, por seis anos, também por tráfico de drogas. (fls. 14). Em Juízo, disse que havia droga na Parati e a estava levando para Pratânia para pagar uma dívida que tinha com um traficante. Era usuário de drogas e estava devendo para o traficante. Sua esposa não tinha conhecimento que estava levando drogas no veículo. Em sua residência havia apenas porções para consumo pessoal e dinheiro para pagar as despesas da casa. Não leu o depoimento que assinou na Delegacia. Não disse que era traficante, tampouco que tinha uma biqueira em Pratânia.

Pois bem. A versão dada em sede policial pelo réu destoa da versão dada em juízo. Assim, em sede policial o réu confessou a prática do crime de tráfico, já em juízo negou o tráfico, alegando que as drogas encontradas no veículo seriam para quitar dívida com traficante e a droga localizada em sua residência era para seu uso pessoal, afirmando, inclusive que não leu o depoimento que assinou na Delegacia. Com efeito, a alegação de que as drogas encontradas no veículo seriam para quitar dívida com traficante não o exime do crime, já que o simples fato de transportar a droga já o insere em um dos verbos do tipo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS-Absolvição Impossibilidade Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos Quantidade e forma de embalagem dos entorpecentes, aliadas às circunstâncias da apreensão, que denotam a destinação mercantil Validade do depoimento dos agentes públicos Crime de conteúdo variado, bastando, para sua consumação, que a conduta se adeque a um dos verbos núcleos do tipo e que as provas evidenciem o intuito de traficância Condenação mantida Pena criteriosamente dosada Básica adequadamente exacerbada em razão da natureza das drogas (cocaína) Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06 Precedentes Inviabilidade de aplicação do redutor insculpido no §4º do art. 33 da Lei de Drogas Circunstâncias que denotam dedicação do réu às atividades criminosas Regime prisional fechado adequado à espécie Detração penal não aplicável Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse 'Quantum' de pena corporal aplicada que impede a sua substituição por restritiva de direitos Recurso desprovido(TJSP- Apelação Criminal nº 1501387-59.2019.8.26.0535; Relator(a): Camilo Léllis; Comarca: Guarulho; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 18/02/2020; Data de publicação: 20/02/2020).

Ademais, a versão do réu restou dissociada dos elementos de prova constantes nos autos, notadamente a prova oral, consistente nos depoimentos convictos, coesos e harmônicos entre si dos policiais ouvidos em juízo.

Não há qualquer motivo para desacreditar da autoridade policial ouvida em juízo, vez que compromissada e sujeita às penas previstas no art. 342 do Código Penal.

Ademais, não se logrou demonstrar que as autoridades policiais ouvidas sob o crivo do contraditório eventualmente foram parciais ou nutriram interesse em prejudicar o acusado, de modo que os seus testemunhos se mostram imaculados e, por isso, constituem meio idôneo de prova.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, o Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o

veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas (TJSP Apelação Criminal nº 1503917-04.2017.8.26.0536; Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 08/04/2020; Data de publicação: 08/04/2020).

Com efeito, o encontro de drogas e de apetrechos para o tráfico (saquinhos, microtubos e balança de precisão), aliado aos depoimentos dos policiais no sentido de que receberam denúncia anônima de que o réu transportava droga até a cidade de Pratânia diariamente comprovam que o réu estava inserido na dinâmica do tráfico de drogas, sendo suficiente para a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo incompatível com o alegado uso pessoal.

Nesse sentido:

"Tóxico - Tráfico - Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado - Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio - Desclassificação para uso inadmissível." (TJSP - AC 234.718-3 - Rel. Walter Guilherme - j. 17.02.1998 - JTJ 208/273

Ademais, em que pese o réu tenha alegado que o dinheiro encontrado em sua residência era para as despesas da casa, nada comprovou neste sentido (fls. 80).

Por fim, o depoimento da testemunha de defesa nada acrescentou que pudesse favorecer o réu, pois sequer presenciou os fatos.

Além disso, entendo que o réu deve responder também pelo artigo 34 do mesmo dispositivo legal, já que narrado na denúncia a apreensão de sacos plásticos, microtubos (ependofs) e uma balança de precisão, que continha resquícios de cocaína (laudo de fls. 85/88) e, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli) : "O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave".

Demonstrada a ocorrência dos crimes dos artigos 33, caput, e do artigo 34, caput, da lei 11.343/06 e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da denúncia é a medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

Em primeira fase de fixação da sanção, anoto que o réu revela maus antecedentes específicos (fls. 34/35), razão pela qual aumento a pena de 1/3, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

A atenuante da confissão não deve ser reconhecida na hipótese dos autos, pois o artigo 65 do Código Penal exige que ela seja feita sem ressalvas, sem desculpas para o gesto criminoso.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

"A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois em hipótese contrária, inexistente verdade total da dinâmica da ocorrência penal" (TACRIM-SP - Ap. - Rel. Geraldo Lucena - j. 15.05.96 - RJTACRIM 31/84).

"Não deve ser considerada na fixação da pena a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do CP, se no interrogatório do réu este não assinala certos caracteres do fato criminoso, ou seja, limita-se à confissão qualificada" (STF - HC - Rel. Carlos Velloso - j. 17.12.96 - RT 741/558).

Em terceira fase, deixo de aplicar a regra elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois embora o acusado seja primário, demonstrou intenso dolo ao transportar e guardar expressiva quantidade de entorpecentes (303 porções de crack, 1 tijolo de crack, 34 pinos de cocaína), que causaria um grande dano para a coletividade, o que demonstra que o réu estava a se dedicar a atividade criminosa da traficância, afastando a possibilidade de qualquer diminuição, já que o escopo da lei é atingir o traficante esporádico, o que, por óbvio, aqui não se apresenta.

Forçoso concluir-se, pois, que o acusado não se enquadra na categoria de pequeno

traficante ou delinquente esporádico que a lei visa a beneficiar com a aplicação do mencionado redutor, eis que faz do tráfico de drogas seu meio de vida. Por seu turno, relatando a Apelação Criminal nº 0003671-60.2010.8.26.0073 (Comarca de Avaré, j. 25.05.2013), o eminente Desembargador Toloza Neto observou:

"Para a aplicação do referido redutor legal, é indispensável que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Não resta dúvida de que tal causa de diminuição de pena é de ser aplicada apenas àquele que tenha praticado o delito de maneira isolada, como um pequeno deslize em sua vida, ainda que penalmente punível. Aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida, mesmo que não tragam em sua folha de antecedentes condenações por outros crimes, não fazem jus ao benefício. A causa de redução deve ser aplicada em caráter excepcional, em situações específicas, quando não houver dúvidas de que o réu veio a cometer o ato como um desvio em sua vida, e não de modo contumaz e habitual."

Nesse sentido é o posicionamento do E.TJ/SP, no seguinte julgado:

"Lei de Tóxicos (nº 11.343/06). Tráfico. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento impassível de abrandamento. Fixação da pena base no mínimo legal, diante da aplicação dos critérios explicitados em determinação do C. S.T.J. Inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Regime inicial fechado -único possível. Inviabilidade de substituição da corporal por penas alternativas. Apelo improvido." (Apelação nº 0022448-60.2013.8.26.0050, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, j. 29/01/2019).

Artigo 34, caput, da Lei 11.343/06

Em primeira fase, pelos maus antecedentes específicos do réu, aplico a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 1600 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Considerando o concurso material de delitos, a pena definitiva do réu será de 10 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 2266 dias-multa.

Tendo em vista o montante da pena e por se tratar de crime equiparado a hediondo (artigo 2º da Lei nº 8.072/90), estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

Sobre a pertinência da fixação de referido regime de cumprimento de pena, trago o seguinte precedente:

"Por fim, mantenho o regime inicial fechado para início do desconto da corporal, sendo o único compatível com o delito, dada a determinação legal em se tratando de crime hediondo (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90). Cumpre observar que o ilícito do qual ora se trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado permitirá aos réus uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, AP 0002479-41.2010, Rel. Edison Brandão, j. 02/07/2013).

Como se sabe, a finalidade da lei é proteger a saúde pública, evitando-se o dano que o uso de drogas causa à saúde e a única forma de se coibir tal prática, com sucesso, é através do combate ao narcotráfico e da não permissão de que aqueles que se vêem acusados e até condenados de tais práticas sejam, desde logo, reintegrados ao convívio social, sem que percebam a gravidade de suas ações.

No mais, persistem inalteradas todas as razões já expostas por força da decisão que decretou a prisão preventiva do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu JESSUÉ APARECIDO DE ALMEIDA, à pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 2266 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso nos artigos 33, caput e artigo 34, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, bem como dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão, pois são instrumentos, produtos ou proveito do crime em apreço. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

O réu, diante da necessidade da prisão cautelar durante todo o processo e desta condenação que a ratifica, não poderá apelar em liberdade, pois reputo que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva. Recomende-se-o na prisão em que se encontra, com as cautelas de praxe.

Honorários proporcionais

Custas na forma da Lei.

Botucatu, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA